

学生A、B及びCは、不真正不作为犯の作為義務違反に関して次の【会話】のとおり検討している。【会話】中の①から⑤までの（ ）内から適切な語句を選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、【会話】中の「法律上の防止義務」とは、法令、法律行為、条理等に基づき法益侵害を防止する法的義務をいい、また、いずれの事例も結果回避は容易であったとする。

【会 話】

学生A. 「甲は、人通りの多い市街地で自動車を運転していた際、誤って乙を跳ねて重傷を負わせたが、怖くなったことから、乙を放置したまま逃走したところ、乙が死亡した。」という事例において、殺人罪の成否に関し、不真正不作为犯の作為義務を検討してみよう。私は、不真正不作为犯の作為義務違反は、法律上の防止義務を負う者が、法益侵害への因果関係を具体的・現実的に支配している状況下で防止措置を採らなかった場合に認められると考えるので、甲には作為義務違反が①（a. 認められる・b. 認められない）ことになる。

学生B. 私は、不真正不作为犯の作為義務違反は、法律上の防止義務を負う者が、既に発生している法益侵害の危険を利用する意思で防止措置を採らなかった場合に認められると考えるので、この事例では、甲には作為義務違反が②（a. 認められる・b. 認められない）ことになる。

学生C. 私は、不真正不作为犯の作為義務違反は、法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定した者が、その法益侵害の防止措置を採らなかった場合に認められると考えるので、この事例では、甲には作為義務違反が③（a. 認められる・b. 認められない）ことになる。

学生A. 次に、「一人暮らしをしている丙は、自宅に遊びに来ていた丁が帰った後、丁のたばこの火の不始末でカーテンが燃えているのに気付いたが、家に掛けてある火災保険の保険金を手に入れようと考え、そのまま放置して外出したところ、カーテンの火が燃え移って家が全焼した。」という事例において、非現住建造物等放火罪の成否に関し、不真正不作为犯の作為義務を検討してみよう。C君の立場からだと、丙には作為義務違反が④（a. 認められる・b. 認められない）ことになるよね。

学生B. 先ほど話した私の立場からは、今の事例では、丙には作為義務違反が⑤（a. 認められる・b. 認められない）ことになる。

1. ①a ②b ③a ④a ⑤b
2. ①a ②a ③b ④a ⑤b
3. ①b ②a ③a ④b ⑤b
4. ①b ②b ③a ④b ⑤a
5. ①b ②b ③b ④a ⑤a

No.23	不真正不作为犯	正答率 91%
共通H28-1	正解 4	

() には、順に「①b ②b ③a ④b ⑤a」が入り、したがって、正解は肢4となる。

①について

学生Aの立場から、甲に作為義務違反が認められるかが問題となる。学生Aは「不真正不作为犯の作為義務違反は、法律上の防止義務を負う者が、法益侵害への因果関係を具体的・現実的に支配している状況下で防止措置を採らなかった場合に認められる」とする。甲は、乙を救護する法律上の防止義務を負う者に当たる。しかし、甲は、誤って乙を跳ねただけであり、それ以外に引受け等の行為をなんらすることなく、人通りの多い市街地に乙を放置したまま逃走したにすぎないので、甲には法益侵害への因果関係を具体的・現実的に支配している状況は認められない。よって、甲に作為義務違反は認められないので、①には「b. 認められない」が入る。

②について

学生Bの立場から、甲に作為義務違反が認められるかが問題となる。学生Bは「不真正不作为犯の作為義務違反は、法律上の防止義務を負う者が、既に発生している法益侵害の危険を利用する意思で防止措置を採らなかった場合に認められる」とする。甲は、乙を救護する法律上の防止義務を負う者に当たる。しかし、甲は、怖くなったことにより、乙を放置したまま逃走したのであるから、甲には既に発生している法益侵害の危険を利用する意思は認められない。よって、甲に作為義務違反は認められないので、②には「b. 認められない」が入る。

③について

学生Cの立場から、甲に作為義務違反が認められるかが問題となる。学生Cは「不真正不作为犯の作為義務違反は、法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定した者が、その法益侵害の防止措置を採らなかった場合に認められる」とする。甲は、誤って乙を跳ねて重傷を負わせていることから、乙の生命侵害に向かう因果の流れを自ら設定した者に当たる。それにもかかわらず、甲は、乙の生命侵害の防止措置を採ることなく、乙を放置したまま逃走している。よって、甲には作為義務違反が認められるので、③には「a. 認められる」が入る。

④について

学生Cの立場から、丙に作為義務違反が認められるかが問題となる。Cは「不真正不作为犯の作為義務違反は、法益侵害に向かう因果の流れを自ら設定した者が、その法益侵害の防止措置を採らなかった場合に認められる」とする。丙宅が全焼したのは丁のたばこの火の不始末でカーテンが燃えたことを原因とするものなので、丙は公共の危険の発生に向かう因果の流れを自ら設定した者に当たらない。よって、丙に作為義務違反は認められないので、④には「b. 認められない」が入る。

⑤について

学生Bの立場から、丙に作為義務違反が認められるかが問題となる。学生Bは「不真正不作为犯の作為義務違反は、法律上の防止義務を負う者が、既に発生している法益侵害の危険を利用する意思で防止措置を採らなかった場合に認められる」とする。火災発見者に消防署等への通報義務を規定する消防法24条1項、丙宅が火災保険の対象であること、115条に照らせば、丙は通報義務や状況によっては消火活動等の火災を防止する義務などの法律上の防止義務を負う者に当たる。丙は、火災保険の保険金を手に入れるため、既に発生している火災の危険を利用する意思で、通報義務や火災防止義務などの防止措置を採ることなく、カーテンが燃えているのをそのまま放置して外出している。よって、丙には作為義務違反が認められるので、⑤には「a. 認められる」が入る。